

1501182-70.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de anotações referentes à contabilidade do tráfico. Não conhecia o réu, que negou tráfico, esclarecendo que não morava no local. É comum chegarem no condomínio e moradores ou porteiro abrirem o portão, já que há diversas notícias de tráfico por parte de moradores. Não se recorda se apreenderam dinheiro. Havia 3 ou 4 policiais na equipe, mas chegaram outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1501182-70.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501182-70.2022.8.26.0617 2022/000793

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO PAULO VITORIANO DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

PEDRO PAULO VITORIANO DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 23.08.2022, por volta das 17h04min, na Estrada Dom José Antônio do Couto, n.º 5201, Colinas 1 - Campos de São José, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 48 pinos de cocaína (em pó e petrificada), 88 pedras de crack, 12 porções de haxixe, 105 buchas de Cannabis sativa L e 04 frascos de lança-perfume, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos à fls. 238/251.

Recebida a denúncia em 28.09.2022 (fls. 308/310), o réu foi citado pessoalmente (fl. 340). Em audiência, foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fl. 372).

Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, anotando a necessidade de exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas; o reconhecimento da reincidência específica do acusado; a inviabilidade da aplicação da causa especial de diminuição de pena; fixando-se regime inicial fechado (fls. 434/439).

A defesa, a seu turno, buscou preliminarmente, a nulidade da incursão policial e produção de prova que acarretou a prisão do acusado; bem como seja declarado ilícito e desentranhado dos autos o exame grafotécnico produzido, e a isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias. No mérito, buscou a absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal; e o direito de recorrer em liberdade (fls. 443/463).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, indefiro a gratuidade pleiteada, à falta de juntada de declaração de pobreza subscrita pelo interessado.

Quanto ao pedido de declaração de ilicitude e desentranhamento do exame grafotécnico produzido, indefiro-o, reportando-me ao decidido à fl. 406 e repisando que o laudo de fls. 416/423 foi inconclusivo, indicando a necessidade de novo fornecimento de material grafotécnico, que foi negado pelo réu, nos termos da manifestação defensiva de fls. 424/427.

No presente caso, para análise da matéria referente à validade da prova obtida pela busca despida de mandado judicial é necessária aprofundada incursão no mérito, pelo que será com ele analisada, o que passo a fazer.

Em juízo, o réu negou a prática delitativa, dizendo que havia trocado mensagens com Regis agendando seu corte de cabelo às 16h00. Realizou o referido corte de cabelos na área comum do Condomínio Colinas 1, entre os blocos 6 e 8, esclarecendo que a limpeza é realizada pelo último cliente ou pelas "meninas". Após o corte, quando estava se deslocando para o trailer, escutou pessoas gritando "corre", ocasião em que o agente deu um tiro para o alto e falou "é você mesmo", pulando o muro para o condomínio Cajuru 2, onde sua mãe mora. Sabe como os policiais agem e ficou com medo, pois poderia acontecer o pior caso ficasse parado. Não conhecia os policiais. Tem trailler de lanches localizado na frente do condomínio Colinas 2. Acabou se machucando durante a fuga. Não estava com dinheiro quando fora abordado, anotando que cobrava R\$ 10,00 pelo corte. Naquele dia havia cortado os cabelos de Paulinho, Juninho e Regis, sem receber pelo serviço naquele momento. As drogas apreendidas não são de sua propriedade. Não contou sobre os cortes de cabelo para os policiais porque estava machucado e "apagando". Paulinho e Juninho não foram arrolados como testemunhas porque trabalham. Não tem as mensagens que trocou com Regis naquele dia, pois perdeu seu celular na fuga. Terminou de cortar os cabelos de Regis por volta das 16h10min (arquivo digital).

O policial militar FÁBIO DA SILVA asseverou que o local, conhecido pelo tráfico de drogas, fica em plano mais baixo que a via, de modo que todas as vezes que tentam fazer patrulhamento são vistos pelos traficantes antes de acessarem o local, o que possibilita a fuga deles. Visualizaram o acusado traficando dentro do condomínio, na parte do fundo, onde é realizado o tráfico, na posse de uma sacola. Ele empreendeu fuga entre os blocos ao visualizar a equipe, sendo capturado, sem a

sacola, no já condomínio do lado, quando pulava o muro. Realizado percurso por onde ele passou, localizaram a sacola ventilada, dentro de uma caixa de energia elétrica, na qual havia "maconha", cocaína, crack e lança perfume, além de anotações referentes à contabilidade do tráfico. Não conhecia o réu, que negou tráfico, esclarecendo que não morava no local. É comum chegarem no condomínio e moradores ou porteiro abrirem o portão, já que há diversas notícias de tráfico por parte de moradores. Não se recorda se apreenderam dinheiro. Havia 3 ou 4 policiais na equipe, mas chegaram outras viaturas posteriormente. Dois ou três policiais desembarcaram com arma em punho. Negou terem atirado (arquivo digital).

No mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda LEANDRO DO PRADO MORAES, narrando que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando, pela rua lateral, avistaram o acusado, na posse uma sacola plástica de cor vermelha, no interior do condomínio, empreendendo fuga ao avistar a equipe. Desceu da viatura e o abordou após breve perseguição, quando ele estava caído no chão após pular o muro do condomínio. Realizaram busca pelo local onde o acusado passou durante a fuga, localizando dentro de uma caixa de luz a sacola citada, na qual havia 'maconha', cocaína e crack. Ele negou ser morador do condomínio. Foi possível identificar a sacola em razão da cor e material. Quando ingressaram no condomínio o portão estava aberto e não visualizou o porteiro. Não conhece a pessoa que abre o portão para viatura quando ele está fechado. (arquivo digital).

A testemunha REGIS DUARTE DE JESUS afirmou que no dia dos fatos cortou o cabelo com o acusado, e que depois subiu para sua casa, por volta das 16h00. Ele é barbeiro e corta cabelos no condomínio Colinas 1, onde tem amigos, tendo cortado seu cabelo do lado de fora, perto do apartamento de um amigo dele, chamado Paulinho, sem saber informar o número e bloco do apartamento. Não soube dizer quem limpou o local após o corte. O acusado não cortava em sua própria casa porque morava com a mãe e ela brigava por conta da sujeira deixada após o corte. Além disso ele tem um trailer perto do condomínio, na estrada do Cajuru, próximo à portaria. Algum parente do réu mora do condomínio. Para acessar o local é necessário que morador autorize a entrada por meio de interfone. Ficou sabendo posteriormente que o acusado havia sido preso (arquivo digital).

A testemunha MONICA SOARES DE OLIVEIR disse que moradora do condomínio fechado Cajuru 2 e representante de torre. O acesso ao local é autorizado apenas por moradores, de forma remota, por meio de aplicativo e digital. Acredita que os policiais acessaram o local por meio do "vácuo" de outro carro. Márcia Vitoriano, PEDRO VITORIANO e seu irmão são moradores da torre. O condomínio Colinas 1 e 2 fica ao lado, onde a entrada deve ser autorizada por porteiro. o Colinas 1. No dia dos fatos não estava no local. O réu sempre circulava nos condomínios entregando lanches e realizando cortes de cabelo. O acusado tem um trailer perto da portaria (arquivo digital).

Os laudos periciais de fls. 31/34 e fls. 353/356 atestam que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína, tetrahydrocannabinol (THC), e tricloroetileno que, como se sabe, são drogas.

A versão fornecida pelo réu, além de não convencer, é infirmada pelas seguras e harmônicas palavras dos policiais, prova documental (imagens registradas pelas câmeras estatais quando da diligência e disponíveis no link de fl. 336) prova pericial, que confirmam a existência e autoria delitivas.

De fato, sua alegação de que estava no local realizando corte de cabelo de Paulinho, Juninho e Regis, não se compraz com a ausência de dinheiro em seu poder (não convencendo a escusa de que os três clientes pagariam posteriormente), ou de qualquer instrumento comumente utilizado para a prática deste ofício, seja tesoura, pente, ou cortador de cabelo elétrico.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheçam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse deles em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

O relato dos agentes, testemunhas compromissadas, outrossim, prevalece ante o da testemunha de defesa Regis, pessoa próxima do réu (amigo), que sequer presenciou a abordagem, apresentado depoimento confuso em relação ao local do condomínio onde seu suposto corte de cabelo fora realizado.

Os harmônicos relatos dos policiais (os quais não destoam das imagens registradas pelas câmeras estatais quando da diligência e disponíveis no link de fl. 336), logo, preponderam ante a pueril negativa do réu e inverossímil e contraditório depoimento da testemunha de defesa.

Não é demais anotar que, tivessem imbuídos os policiais do propósito de incriminar falsamente o corréu, para tanto seria desnecessário desperdiçar tamanha quantidade de droga (348 pinos de cocaína, 88 pedras de crack, 12 porções de haxixe, 105 buchas de Cannabis Sativa L e 04 frascos de lança-perfume), com alto valor econômico, porquanto poderiam atingir seu desiderato com pouco invólucros.

Sumulando, a palavra dos policiais, que, durante patrulhamento avistaram o réu, que trazia consigo uma sacola plástica e, ao perceber a presença da equipe policial, empreendeu fuga, deixando, em uma caixa de luz no chão o objeto, sendo ele na sequência detido e a sacola referida apreendida, em cujo interior fora localizada expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (194,04g de tetrahidrocannabinol, 40,49g de cocaína e 22 mililitros de Tricloroetileno, divididos em 48 pinos de cocaína, 88 pedras de crack, 12 porções de haxixe, 105 buchas de Cannabis sativa L e 04 frascos de lança-perfume, fls. 31/34), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu tinha em depósito, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Resta, portanto, analisar a legitimidade da busca e apreensão empreendida pela polícia sem mandado judicial e consequente validade dos elementos de prova por meio dela obtidos (no caso específico as drogas).

O precedente judicial que deve pautar esta análise é o prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, Corte a que em nosso ordenamento cabe a última palavra em matéria constitucional.

Eis sua ementa:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o

flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 -DIVULG 09-05-2016 - PUBLIC 10-05-2016)

No caso concreto, do relato dos policiais (os quais não destoam das imagens registradas pelas câmeras estatais quando da diligência e disponíveis no link de fl. 336), tanto na fase policial quanto judicial, extrai-se que eles estavam em patrulhamento em via pública (Estrada do Cajuru), quando visualizaram o réu dentro do condomínio ventilado, conhecido ponto de tráfico, na posse de uma sacola, o qual empreendeu fuga quando visualizou a viatura.

Essas circunstâncias objetivas são suficientes a evidenciar a fundada suspeita da prática de crime permanente a autorizar a diligência independentemente de mandado judicial, ex vi do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Como bem ressaltou Min. Gilmar Mendes, relator do julgado referido, em seu voto, "(...) do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. (...). Por estar a certeza fora do alcance, a legislação costuma exigir modelos probatórios bem mais modestos para medidas de investigação. Para busca e apreensão, por exemplo, o Código de Processo Penal exige apenas 'fundadas razões' - art. 240, §1º".

Diante desse quadro, não há qualquer ilegalidade a sanar, sendo as provas obtidas plenamente lícitas.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes excludentes legais, impositiva a condenação do réu nas suas penas.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência específica (condenação referente ao processo nº 000702-79.2016, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa em 07.11.2017 – fls. 42/43), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade e variedade e natureza de droga apreendida (40,49 g de cocaína, divididos em 48 pinos e 88 pedras de crack, 12 porções de haxixe, 194,04 g de Cannabis sativa L, divididos em 105 buchas e 04 frascos de lança-perfume), tudo a revelar a intensidade do comércio espúrio.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Sendo o réu reincidente específico, majoro suas penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

“Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes.

Inexistem causas de aumento.

Anoto que devido à reincidência específica do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime de cumprimento de pena é o inicialmente fechado, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A mera quantidade da pena, além de recidiva e circunstâncias judiciais desfavoráveis, obstem a substituição ou concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, PEDRO PAULO VITORIANO DE ARAUJO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Deverá o acusado permanecer presa para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Custas ex lege.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA